

1500658-50.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256348/2022 - 02º D.P. MONGAGUA, 27528303 - 02º D.P.

MONGAGUA, 2256348 - 02º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEN BRITO SANTOS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500658-50.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500658-50.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256348/2022 - 02º D.P. MONGAGUA, 27528303 - 02º D.P.

MONGAGUA, 2256348 - 02º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEN BRITO SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de WESLEN BRITO SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos Lei 11.343/06, e no artigo 349-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, afirmando que "no dia 19 de setembro de 2022,

por volta das 12h50, na Avenida dos Mariscos, n. 500, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, nesta mesma cidade e comarca, o acusado trazia consigo, sem autorização e para fins de tráfico, 12 porções de cocaína, com peso total bruto de 55g (...). Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado tentou ingressar com 05 aparelhos telefônicos de comunicação móvel, da marca LB STAR, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, sem autorização legal, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.”

Audiência de Custódia realizada em 20 de setembro de 2022, momento em que homologada a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ainda na ocasião, a denúncia foi recebida e o réu citado (fls. 51/53).

Resposta à acusação apresentada a fls. 50.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 25 de novembro de 2022, momento em que ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e interrogado o réu (fls. 94/95).

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da pretensão punitiva, tendo em vista a presença de materialidade e provas suficientes de autoria.

A Defesa Técnica do réu também se manifestou oralmente. Aduziu, em síntese, ocorrência de coação moral irresistível, acarretando absolvição do acusado em razão da excludente de culpabilidade. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos Lei 11.343/06, e no artigo 349-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não há questões preliminares a ser analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade de ambos os crimes está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 13), laudo toxicológico definitivo (fls. 69/71), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. A autoria também é certa.

A testemunha Heleno Dominone César Filho, agente penitenciário, na fase policial (fls. 02), disse que (a) na data dos fatos, por volta das 12h50min, o reeducando Weslen, ao retornar da saída temporária, foi submetido a revista corporal por meio de equipamento de detector de metais, acionado alarme sonoro e luminoso, (b) em razão da fundada suspeita, o réu foi submetido a revista por meio de scanner corporal, encontrados 05 objetos metálicos semelhantes a micro aparelhos celulares, (c) de imediato, o acusado confessou que estava transportando somente os celulares, (d) encaminhado ao Pronto Socorro, expeliu pela boca 05 aparelhos celulares da marca LB STAR, 05 fones de ouvido sem fio e 12 porções de substância branca aparentando ser cocaína. Em juízo, (e) confirmou o relato anteriormente trazido, acrescentando que naquele dia era retorno dos detentos que estavam fora, (f) quando Weslen retornou, o detector foi acionado, algo que só ocorre quando se está portando metal, (g) passaram por scanner corporal, decidindo encaminhá-lo à enfermaria para melhor averiguação, (h) no próprio estabelecimento, começou a

expelir os celulares e cocaína, (i) o Weslen cooperou, não deu trabalho nenhuma aos agentes.

A testemunha Ivan Ferreira dos Santos Júnior, agente penitenciário, ouvido em solo policial (fls. 03), disse que (a) na data dos fatos, por volta das 12h50min, o reeducando Weslen, ao retornar da saída temporária, foi submetido a revista corporal por meio de equipamento de detector de metais, acionado alarme sonoro e luminoso, (b) em razão da fundada suspeita, o réu foi submetido a revista por meio de scanner corporal, encontrados 05 objetos metálicos semelhantes a micro aparelhos celulares, (c) de imediato, o acusado confessou que estava transportando somente os celulares, (d) encaminhado ao Pronto Socorro, expeliu pela boca 05 aparelhos celulares da marca LB STAR, 05 fones de ouvido sem fio e 12 porções de substância branca aparentando ser cocaína. Em juízo, disse que não se lembra exatamente que dia foi, (b) o reeducando foi autuado porque foi soado o alarme do detector de metal, e posteriormente levado ao scanner de esteira, (c) não se recorda que Weslen tenha lhe dito sobre um traficante o teria obrigado a ingressar do estabelecimento prisional com a droga e os celulares.

O acusado Weslen Brito Santos, em solo policial (fls. 04), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva nos termos da denúncia. Disse que (a) em sua juventude, teve diversos problemas com cocaína, ao chegar na unidade penitenciária de Mongaguá, acabou tendo uma recaída e devido a essa situação, criou dívida grande com um traficante chamado Douglas, (b) no dia de retornar à unidade, na própria rua do estabelecimento, o traficante lhe cobrou a quantia devida, que o prazo havia acabado e não haveria tolerância quando a isso, (c) foi pedido novo prazo de pagamento, mas foi negado, (d) o réu foi levado a um terreno baldio, onde havia outros dois indivíduos, aguardando, inclusive com armas de fogo, (e) foi-lhe dito que se ingressasse com a droga e os celulares, seria abatida a dívida dele.

Pois bem. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ainda, o próprio réu confessou a prática do delito a ele imputado. Portanto, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

A tese defensiva, relativa à existência de ameaça perpetrada por traficante de drogas, fato que ocasionaria em excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível, não comporta acolhimento. Não existem outros elementos que corroborem a alegação, tão somente a própria palavra do acusado.

Aliás, insta salientar que o n. Defensor de Weslen insistiu na oitiva de um dos agentes penitenciários que não se apresentou nesta audiência, envidando este Magistrado esforços no sentido de localizar a testemunha e ouvi-lo em audiência. Ocorre que a testemunha não corroborou a tese defensiva, restringindo-se a dizer aquilo que já constava em seu depoimento prestado em solo policial.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, os fatos praticados preenchem todas as elementares dos tipos penais positivados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos Lei 11.343/06, e no artigo 349-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que os agentes são imputáveis e que não

estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Não foram, pois, comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que foi praticada conduta típica e ilícita e por agente culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Quanto as causas modificativas da pretensão punitiva, verifica-se que o acusado é multirreincidente, ostentando mais de uma condenação criminal transitada em julgado (fls. 39/42), razão pela qual será aplicada tanto a agravante prevista no art. 61, I, CP, quanto considerada a circunstância negativa relativa aos antecedentes.

Em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/06, constata-se que foi "cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais", fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas. Trata-se de patamar variável de aumento da pena (entre um sexto a dois terços). Considerando não existirem maiores elementos para a valoração negativa neste aspecto, pois ínsitos à própria causa de aumento, reputo suficiente o aumento da pena no patamar mínimo, qual seja, de 1/6 da pena.

Quanto ao crime de favorecimento real especial (art. 349-A, Código Penal), incide a causa de diminuição da pena relativa à tentativa (art. 14, inciso II, Código Penal), pois o efetivo ingresso dos aparelhos telefônicos no estabelecimento prisional apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Trata-se de patamar variável de diminuição da pena (entre um a dois terços). Considerando que a concretização do delito não ocorreu tão somente em razão das diligências dos agentes penais, que realizaram buscas minuciosas no acusado, entendo que a diminuição deve ser aplicada no mínimo legal, qual seja, de 1/3 da pena.

Por fim, constato que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, embora nas mesmas circunstâncias de tempo e local, fazendo incidir a regra prevista no art. 69, caput, Código Penal. Saliento, ainda, que a aplicação do estatuto do concurso formal, positivado no art. 70 do Código Penal, seria desfavorável ao réu e, portanto, esbarraria na vedação contida em seu parágrafo único.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI). Tendo em vista que foram dois os crimes cometidos, com naturezas distintas da pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), a dosimetria será realizada separadamente.

- Artigo 349-A do Código Penal:

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. fls. 39/42 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Quanto às circunstâncias do crime, constato que foram 05 aparelhos celulares apreendidos com o acusado, razão pela qual cabível a valoração negativa nesta fase. Os motivos da infração penal não podem ser valorados negativamente no presente cenário. As consequências da infração penal são ínsitas ao tipo penal. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve

observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 05 meses e 07 dias de detenção.

Na segunda fase, constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Ocorre que o acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Procedo a compensação integral entra agravante e atenuante, em consonância à jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ (Sexta Turma. HC n. 714505/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 23 de agosto de 2022). Por esta razão, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado, qual seja, 05 meses e 07 dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento da pena. Conforme dito alhures, porém, o delito ocorreu na modalidade tentada, incidindo o patamar mínimo de diminuição da pena, de 1/3. Assim, fixa-se a pena definitiva em 03 meses e 14 dias de detenção.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, tendo praticado o crime ora em análise quando ainda estava em cumprimento da pena anterior. Bem por isso, com base no art. 33, caput, c/c §2º, "b", do CP, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista a reincidência e circunstâncias judiciais negativas do crime praticado.

- Art. 33, caput, Lei n. 11.343/06:

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do

art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constatado que a quantidade da droga apreendida se mostra suficiente para valoração na presente fase, pois consistente em 46,7g de cocaína. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. fls. 39/42 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação às outras circunstâncias judiciais, não há elementos aptos à valoração negativa. Portanto, considerando duas circunstâncias negativas, fixo a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Ocorre que o acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Procedo a compensação integral entre agravante e atenuante, em consonância à jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ (Sexta Turma. HC n. 714505/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 23 de agosto de 2022). Por esta razão, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado, qual seja, 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de diminuição da pena. Conforme fundamentação supra, há a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, Lei de Drogas, ora fixada no patamar de 1/6. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 08 anos e 09 meses de reclusão, além do pagamento de 875 dias-multa.

A título de observação, consigno que não estão presentes os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do acusado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, tendo praticado o crime ora em análise quando ainda estava em cumprimento da pena anterior. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "b", do CP, estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, bem como da reincidência específica e circunstâncias judiciais negativas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar WESLEN BRITO SANTOS (a) à pena de reclusão, pelo prazo de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como no pagamento de 875 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06; (b) à pena de detenção, pelo prazo de 03 meses e 14 dias, em regime inicial semiaberto, em virtude da conduta típica descrita no art. 349-A c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Sendo o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA